

1501878-39.2022.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação.

Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501878-39.2022.8.26.0510 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501878-39.2022.8.26.0510 - 2022/000484

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Neves da Silva de Brito

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

GABRIEL NEVES DA SILVA DE BRITO, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 05 de julho de 2022, por volta das 16:10 horas, na Rua 20 BV, entre as Avenidas 86 e 88, Boa Vista, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 300 (trezentos) microtubos contendo a substância entorpecente denominada cocaína, e ainda guardava e tinha em depósito outros 1500 (mil e quinhentos) microtubos com a mesma substância entorpecente, totalizando peso líquido de 433,8 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo de constatação de fls. 20/24 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 45/47, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 06 de setembro de 2022. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, impossibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, com fixação de regime prisional inicial fechado.

Já a ilustre Defensora, diante da confissão externada pelo acusado, reequereu seja a pena-base fixada no mínimo legal, com reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, devendo incidir ainda o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime prisional aberto, facultando-se, por fim, a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo, e ainda guardava e tinha em depósito o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 45/47, com resultado positivo para cocaína.

E a autoria atribuída ao acusado foi igualmente evidenciada.

Ouvido em juízo, o acusado admitiu que na ocasião dos fatos foi efetivamente abordado por Policiais Militares, quando se encontrava junto a uma árvore, mantendo no local um mil e oitocentos "eppendorfs" contendo cocaína, negando, entretanto, tivesse empreendido fuga, para buscar homiziar-se em um matagal próximo. Observou que estava mantendo o entorpecente depositado naquele local, em favor de terceiro, em razão de dívida contraída anteriormente, mas que também entregava rotineiramente parte da droga a indivíduos que se encarregavam de distribuir no bairro. Por fim, afirmou o acusado que, no momento em que abordado, sofreu violência por parte dos Policiais Militares, suportando uma mordida no braço e pisada no ombro.

A não se dizer isolada, a confissão externada pelo acusado foi amparada pela prova oral produzida.

De fato, os Policiais Militares ouvidos em juízo, reiterando o que exposto contemporaneamente aos fatos, afirmaram que na ocasião avistaram inicialmente o acusado junto ao canteiro de uma árvore, tendo ele empreendido fuga, quando da aproximação da guarnição, carregando consigo um pacote. Acrescentaram que ele ingressou em seguida em uma mata, onde acabou sendo abordado, apreendendo-se em poder dele trezentas porções de cocaína. Posteriormente, em busca realizada no local onde anteriormente avistado o acusado, localizaram outras mil e quinhentas porções de cocaína, embaladas da mesma forma que aquela que estava em poder do acusado, negando tivesse havido qualquer violência empregada contra o acusado. Diante do que vem de ser exposto, nenhuma dúvida existe sobre a posse do entorpecente, tendo sido tal circunstância admitida inclusive pelo próprio acusado, bem assim a destinação mercantil, a configurar, portanto, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida (mil e oitocentas porções de cocaína), reconhecidamente destinada à distribuição no bairro onde estava depositada, deve a pena-base ser fixada pouco acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em função das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, deve a pena-base retornar para o patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

E não há lugar para a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. É que embora o acusado seja primário, ostenta diversos

registros na Vara da Infância e Juventude desta Comarca, inclusive cinco por atos infracionais equiparados a tráfico ilícito de entorpecentes, já lhe tendo sido aplicada a medida socioeducativa de internação, sendo certo que, embora os registros infracionais não sejam considerados maus antecedentes, são aptos à verificação da personalidade do agente e, por aqui, também da dedicação à atividade ilícita.

Sobre isto: "Agravamento regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do juízo de origem. Precedentes. Agravamento regimental não provido". (AgR HC 200302, STF. 1ª Turma. Rel: Min Dias Toffoli, julgado em 31/05/2021)

E ainda: "(...) Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravamento regimental não provido." (RHC 190434 AgR. STF. 1ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/08/2021).

Assim, a dedicação à atividade ilícita, ostentando o acusado atos infracionais equiparados ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 25/26), além de ter sido abordado mantendo em depósito mil e oitocentos "ependorfs" contendo cocaína, a indicar profundo envolvimento e dedicação à atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, à mencionada causa especial de redução.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado GABRIEL NEVES DA SILVA DE BRITO à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, CP), cuida-se de delito de natureza hedionda, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispondo o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, proferida do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de

forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interdita a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descuidar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

Sobre isto: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1). E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inexistência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA